

1524992-77.2022.8.26.0228

Classe: Inquérito Policial

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ROBERTA HALLAGE GONDIM TEIXEIRA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... apenas pelo crime de receptação, devendo o tráfico de drogas ser desclassificado para o delito descrito do artigo 28 da Lei 11.343/06.

No caso em testilha, as provas amealhadas nos autos trazem tranquilidade necessária ao édito condenatório do acusado, contudo, apenas como incurso nas sanções da receptação, devendo o tráfico de drogas ser desclassificado para o crime do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

4ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1524992-77.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1524992-77.2022.8.26.0228_Controle 2022/001422

Classe - Assunto

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIOGO QUEIROZ DA SILVA NASCIMENTO

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ROBERTA HALLAGE GONDIM TEIXEIRA

Vistos.

DIOGO QUEIROZ DA SILVA NASCIMENTO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, combinados, na forma do artigo 69, com o artigo 180, caput, estes últimos do Código Penal.

Segundo consta na denúncia, entre 17 de outubro e 05 de novembro de 2022, em local incerto desta capital, DIOGO QUEIROZ DA SILVA NASCIMENTO, adquiriu e recebeu o aparelho de telefone celular Samsung Galaxy A12, avaliado em R\$1.000,00, pertencente a Miguel Manoel da Silva, coisa que sabia ser produto de crime.

Consta, também, que aproximadamente às 09h30min do dia 05 de novembro de 2022, na Rua Rego Freitas, altura do nº10, República, nesta capital, DIOGO QUEIROZ DA SILVA NASCIMENTO trazia consigo drogas para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo foi apurado, Miguel Manoel da Silva teve seu celular furtado do interior do

seu veículo em 16 de outubro de 2022, conforme B.O. HX1085-1/2022 do 2ª DP de Campinas.

Menos de um mês depois, policiais militares faziam patrulhamento rotineiro e desconfiaram da conduta de DIOGO, que conversava com terceiros na via pública e, ao notar a aproximação da viatura, escondeu um objeto que trazia nas mãos.

Em revista pessoal, no tênis do acusado foram encontrados 06 invólucros plásticos fechados por aquecimento contendo ao todo 4g de cocaína; em poder de DIOGO os policiais também encontraram o celular apreendido, que constava como produto de furto.

O réu foi preso em flagrante e, em audiência de custódia, teve a prisão convertida em preventiva (fls. 47/50).

A denúncia foi recebida em 17 de novembro de 2022, ocasião em que se designou audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 15 de dezembro de 2022, às 14h30min (fls. 67/70).

O réu foi citado em audiência e apresentou resposta escrita à acusação também durante a audiência, sendo afastadas as hipóteses de absolvição sumária e ratificada a denúncia.

Foi realizada a audiência acima designada, na qual foram ouvidas a vítima e duas testemunhas arroladas pelas partes. Na sequência, o réu foi interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação, nos termos da denúncia.

A Defesa do réu, por sua vez, requereu a absolvição, por falta de provas. Subsidiariamente, requereu a desclassificação da conduta para o crime de uso de drogas para o consumo pessoal, assim como, a fixação da pena-base no mínimo legal, a determinação de regime inicial diverso do fechado, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e o reconhecimento do direito de apelar em liberdade.

É o relatório.
Fundamento e Decido.

A pretensão punitiva estatal é parcialmente procedente.

A autoria e a materialidade do crime imputado na denúncia ficaram provadas, em especial pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 06), pelo laudo de constatação (fls. 08/10), pelo boletim de ocorrência (fls. 11/13 e 30/31), pelo exame químico-toxicológico (fls. 89/91), o qual restou positivo para a substância cocaína, constante na lista F1 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores; bem como pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Em depoimento realizado em juízo, a vítima Miguel Manoel da Silva contou que tem uma oficina mecânica e havia deixado seu telefone celular na banco do carro. Quando foi à feira percebeu que o celular não estava mais no local em que havia deixado. Isso aconteceu há mais ou menos dois meses, em meados de outubro de 2022. Seu telefone era um Samsung galaxi.

Em depoimento realizado em juízo, o policial militar Evellyn Barbosa Brandão de Almeida contou que no dia dos fatos, por volta das 09h35min, estava em patrulhamento pela Rua Rego Freitas, no bairro da República, quando avistou um indivíduo, que posteriormente soube se chamar DIOGO QUEIROZ DA SILVA NASCIMENTO,

sentado na frente de um estabelecimento comercial fechado. Viram que ele estava portando um saquinho contendo um pó branco. Então retornaram com a viatura para melhor averiguação. Em revista pessoal nada foi encontrado, então pediram para o réu tirar os tênis, ocasião em que localizaram três papелotes de cocaína em cada tênis. O local é conhecido como ponto de venda de drogas e de uso também. No local estava apenas o acusado, não havia usuários ao redor naquele momento. O réu estava na posse de um telefone celular, contou que era garoto de programa, tinha feito um programa e como a pessoa não tinha como efetuar o pagamento, entregou este telefone celular como meio de quitar o débito.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar Flávio Rafael Biazon, que confirmou integralmente a versão do seu colega de farda. A testemunha se recordou dos fatos e do acusado. Contou que estavam em patrulhamento pelo local dos fatos quando visualizaram o acusado com uma substância na mão que parecia ser entorpecente. Após o retorno fizeram a busca pessoal e no corpo dele, inicialmente nada foi encontrado, após, pediram para ele retirar o tênis e com ele foi localizado três porções em cada tênis. Em seguida, com o réu foi encontrado um telefone celular. Em consulta confirmaram que referido telefone era produto de furto.

Ao ser interrogado em juízo, o réu DIOGO QUEIROZ DA SILVA NASCIMENTO contou que estava com três porções de cocaína nos seus tênis. Disse que havia outras pessoas no local. Após encontrarem a droga, pegaram seu telefone celular, mas o interrogando não sabia que era produto de crime. Recebeu este telefone de um cliente, após um programa, pois trabalha como garoto de programa. O cliente não deu nota fiscal, apenas retirou o chip e entregou o aparelho. Não sabia se este cliente iria voltar. Estava com o celular há uma semana e meia. Não tinha outro telefone celular. Trabalhava apenas como garoto de programas. Em relação as drogas, afirma que estas eram para seu consumo. Usa drogas apenas para fazer os programas. Estava morando em uma pensão. Tem familiares na cidade, como sua avó. Parou de estudar no primeiro ano do Ensino Médio.

Quando ouvido na Delegacia de Polícia, declarou que é "garoto de programa" e questionado sobre a droga que trazia consigo, disse que adquire a droga para que seus clientes a utilizem durante o programa e que no final pede ao cliente que ajude no valor da droga. Questionado sobre o aparelho de celular, disse que há 15 dias, um cliente não tinha dinheiro para lhe dar e que disse para o interrogado ficar com o telefone como forma de pagamento e que pediu apenas para retirar o chip do aparelho e que não sabia que o aparelho era produto de crime.

Essa é, em síntese, a prova oral colhida.

O conjunto probatório é suficiente para fundamentar a condenação do réu, contudo apenas pelo crime de receptação, devendo o tráfico de drogas ser desclassificado para o delito descrito do artigo 28 da Lei 11.343/06.

No caso em testilha, as provas amealhadas nos autos trazem tranquilidade necessária ao édito condenatório do acusado, contudo, apenas como incurso nas sanções da receptação, devendo o tráfico de drogas ser desclassificado para o crime do artigo 28 da Lei 11.343/06.

Em relação à receptação, não há dúvidas de que o acusado DIOGO QUEIROZ DA SILVA NASCIMENTO recebeu, em proveito próprio, aparelho de telefone celular Samsung Galaxy A12, avaliado em R\$1.000,00, mesmo sabendo tratar-se de produto de crime.

No caso em tela, constatou-se que a vítima Miguel Manoel da Silva teve o seu telefone celular furtado do interior do seu veículo no dia 16 de outubro de 2022, tal como foi registrado no boletim de ocorrência de fls. 30/31. Ocorre que, no dia 05 de novembro de 2022, o aparelho foi encontrado sob a posse do réu DIOGO, que

alegou ter recebido o celular como forma de pagamento por um cliente que não tinha dinheiro, bem como alegou que não tinha ciência da origem ilícita do bem.

Contudo, a versão do acusado não merece apreço em juízo, sobretudo porque recebeu este telefone, sem notas fiscais, não indicando a qualificação da pessoa que o entregou e em situação na qual era possível ter ciência da origem ilícita do bem.

Sendo assim, o réu apresentou versão e álibi insuficientes diante do conjunto probatório e em momento algum logrou em justificar de maneira convincente a licitude de sua posse.

Desse modo, a versão apresentada em juízo não afasta o dolo de sua conduta, já que adquiriu ou recebeu o telefone celular e, como consequência, assumiu a responsabilidade de ter recebido o bem ilícito para si.

Ademais, ressalta-se que cabe ao acusado o ônus de provar os fatos que alega, nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal.

Frise-se que no crime de receptação, dada a dificuldade da comprovação do elemento subjetivo, a prévia ciência da origem criminosa da coisa deve ser deduzida através dos indícios, conjecturas e circunstâncias exteriores, isto é, para a condenação pelo crime em questão, exige o tipo penal a demonstração da ocorrência do elemento subjetivo do crime. No entanto, tratando-se de um estágio de comportamento meramente subjetivo, é sutil e difícil a prova do conhecimento. Daí porque a importância dos fatos circunstanciais que envolvem a infração e a própria conduta do réu. Nesse sentido:

“RECEPTAÇÃO DOLOSA - Prova - Indícios e presunções - Valor probante reconhecido ante o sistema do livre convencimento adotado pelo Código de Processo Penal. Os crimes de receptação dolosa, via de regra cometidos às escondidas, podem ser provados através de prova indiciária, e circunstancial, a qual, sendo concludente autoriza a condenação” (Apelação nº 597.165/2, Julgado em 09/04/1.991, 4ª Câmara, Relator: - Passos de Freitas, RJDTCRIM 12/118).

“PROVA - Receptação dolosa - Demonstração de que o agente tinha ciência da origem ilícita da coisa, através de conjecturas ou circunstâncias exteriores - Possibilidade: - Inteligência: art. 5º, LVII da Constituição da República. Em se tratando de crime de receptação dolosa, a demonstração de que o agente tinha ciência sobre a origem ilícita da coisa pode ser deduzida de conjecturas ou circunstâncias exteriores, ou seja, do comportamento ab externo, do modus operandi do comprador, uma vez que, não se podendo penetrar no foro íntimo do agente, não há como aferir-se o dolo de maneira direta ou positiva” (Apelação nº 1.050.991/4, Julgado em 10/04/1.997, 7ª Câmara, Relator: - José Habice, RJTACRIM 35/285).

Com isso, tem-se que as circunstâncias que envolvem o delito, como o fato do réu ter adquirido o aparelho de telefone celular sem qualquer elemento comprobatório de origem e procedência do objeto, induzem inexoravelmente à conclusão de que tinha, sim, conhecimento da procedência ilícita do bem, confirmando a autoria do delito de receptação dolosa narrado na denúncia.

Desse modo, não tendo o acusado comprovado a existência de justificativa idônea acerca do recebimento do celular, inviabiliza o pleito de absolvição ou desclassificação para a modalidade culposa de receptação.

De outro lado, em relação ao crime de tráfico de drogas, a prova oral colhida, a qual é insuficiente para a condenação.

Como se verifica, o conjunto probatório juntado aos autos não permite atestar com a devida certeza necessária a prática do delito de tráfico de drogas por parte do

réu, não sendo possível afastar a possibilidade dos entorpecentes apreendidos se destinarem exclusivamente ao consumo próprio.

Com efeito, além da quantidade pequena de drogas apreendidas (4,0g de cocaína), os policiais militares não presenciaram quaisquer indícios de que o acusado estava efetivamente comercializando os entorpecentes no local.

Conforme se depreende da prova oral colhida, os agentes policiais ao chegarem ao local dos fatos, apenas avistaram o acusado sentado na frente de um imóvel, com três porções de cocaína em cada um dos tênis. Não foi apreendido dinheiro com o réu e não havia usuários pelo local.

Assim, não há elementos que indiquem a prática da traficância por parte do acusado, sendo extremamente provável que esta droga se destinasse ao consumo pessoal.

Portanto, pela prova produzida nos autos não é possível afirmar que as drogas encontradas com o acusado seriam por ele vendidas, pois diante da pouca quantidade de entorpecentes apreendidos, da alegada dependência química e das demais circunstâncias fáticas, deve o réu ser apenado na forma do art. 28 da Lei nº 11.343/06, operando-se a desclassificação do delito imputado na denúncia.

Assim, apurada apenas a responsabilidade penal do delito de receptação, passo à dosimetria da pena, segundo o critério previsto no art. 42 da Lei de Drogas e nos arts. 59 e 68 do Código Penal.

Na primeira fase, atenta às circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, observo que a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, sobretudo porque o réu apresenta maus antecedentes (fls. 34/43 e 44/45). Assim, majoro a pena em 1/6 (um sexto), iniciando em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e o pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, verifica-se a ausência de circunstâncias atenuantes. Por outro lado, presente a agravante da reincidência (4ª Vara Criminal de Guarulhos - SP - fls. 34/43 e 44/45 - tráfico de drogas). Com isso, majoro a pena em 1/6 (um sexto), ficando em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e o pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase da dosagem da pena, ausentes causas de diminuição e aumento de pena. Atento a esses critérios, fica a pena do acusado fixada definitivamente em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e o pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Nos termos do artigo 33, §3º, do Código Penal, com fundamento na reincidência de um lado e diante da ausência de violência ou grave ameaça de outro, o regime inicial de cumprimento da pena deverá ser o semiaberto.

Quanto à pena pecuniária, não tendo sido demonstrada condição financeira do réu que justificasse qualquer majoração, cada dia-multa permanecerá em seu valor mínimo, qual seja, 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo dos fatos.

Finalmente diante da reincidência deixo de substituir a pena ou aplicar o sursis por serem incompatíveis.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal promovida contra o réu DIOGO QUEIROZ DA SILVA NASCIMENTO para DESCLASSIFICAR a imputação inicial, de prática do delito previsto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, dando-o como incurso na pena do artigo 28, da Lei nº 11.343/06; bem como para CONDENAR o réu DIOGO QUEIROZ DA SILVA NASCIMENTO, pela prática do crime

previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, arbitrados unitariamente no mínimo legal.

Quanto ao crime de posse de drogas para o consumo pessoal, ante a total impossibilidade de imposição de cumprimento do art. 28 da Lei de Tóxicos, pois se não houver o cumprimento de prestação de serviços à comunidade não há possibilidade de conversão em pena privativa de liberdade, submeto o acusado, nos termos do inciso I do referido dispositivo à advertência sobre os efeitos da droga.

Porque presentes ainda os requisitos da prisão preventiva, reforçados agora pela condenação, nego ao réu o direito ao recurso em liberdade. Oficie-se para transferência do acusado a estabelecimento adequado ao cumprimento da pena, observado o regime semiaberto estabelecido nesta sentença, ressalvada a necessidade de manutenção no fechado, por outra razão. Enquanto aguarda, recomende-se o acusado na prisão em que se encontra.

Porque ausente informação segura quanto ao valor do prejuízo, deixo de estabelecer valor mínimo de reparação civil (art. 387, IV, do CPP).

Com o trânsito em julgado, expeça-se guia para execução definitiva; verifique-se se há fiança para abatimento da pena de multa imposta, nos termos do art. 336 do Código de Processo Penal, bem como da taxa judiciária. Caso não haja fiança ou o valor seja insuficiente, intime-se o(s) réu(s) para pagamento da taxa judiciária no prazo de 60 dias, bem como disponibilize-se a certidão da sentença ao Ministério Público, certificando-se nos autos. Na hipótese de aplicação de pena de multa isolada, cumpra-se o disposto no item 479-A das NSCGJ. Oficie-se ao Instituto de Identificação (IIRGD) e ao TRE/SP, tendo em vista o disposto no art. 15, III, da Constituição Federal; destruam-se as drogas apreendidas.

Condeno os acusados ao pagamento das custas, no valor equivalente a 100 UFESP's, nos termos do artigo 4º, inciso III, item 5, § 9º, alínea "a" da Lei nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003, observada a gratuidade concedida por ser assistido pela Defensoria Pública.

P.R.I.C.

São Paulo, 15 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA